

1500301-45.2021.8.26.0030

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Comarca: Apiaí

Foro: Foro de Apiaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... organização criminosa para o tráfico de drogas¹, o relatório de análise dos dados constantes no aparelho celular apreendido (fls. 174/185), no qual em conversas o denunciado admite atuar no tráfico, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (fls. 27/28), os apetrechos e o dinheiro em espécie evidenciam que o denunciado realizava a venda ilícita de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Apiaí

Foro de Apiaí

Vara Única

Praça Francisco Xavier da Rocha, 182, Apiaí-SP - cep 18320-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500301-45.2021.8.26.0030 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500301-45.2021.8.26.0030

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202729/2021 - DEL.POL.APIAI, 19279276 - DEL.POL.APIAI, 661/21/401 - DEL.POL.APIAI, 2202729 - DEL.POL.APIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEYTON YUKYO ESUMI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de KLEYTON YUKYO ESUMI, qualificado nos autos, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia (fls. 193/194), em data de 28 de julho de 2021, por volta das 07hrs, na Rua da Consolação, nº 448, Santa Bárbara, nesta cidade e Comarca de Apiaí, KLEYTON YUKYO ESUMI tinha em depósito, para fins de comércio

ilícito, uma porção a granel de maconha, pesando aproximadamente 21 (vinte e um) gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Ministério Público: “Segundo o apurado, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 1500282-39.2021.8.26.0030, em razão da suspeita de atuação de KLEYTON no tráfico de drogas, lograram encontrar, no interior da residência uma porção a granel de maconha, peso bruto de 21 gramas, uma balança de precisão digital, vários saquinhos para embalagem de drogas (tipo sacolé) e R\$ 663,00 em espécie. As circunstâncias da apreensão, os elementos probatórios colhidos na investigação que ensejou o mandado de busca e apreensão dando conta que o denunciado integra organização criminosa para o tráfico de drogas¹, o relatório de análise dos dados constantes no aparelho celular apreendido (fls. 174/185), no qual em conversas o denunciado admite atuar no tráfico, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes (fls. 27/28), os apetrechos e o dinheiro em espécie evidenciam que o denunciado realizava a venda ilícita de entorpecentes”.

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no qual foram encadernadas, entre outras, as seguintes peças: auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), termos de declarações (fls. 02, 03, 04, 05/06, 157, 158, 159 e 173), autos de exibição e apreensão (fl. 12 e 160), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 12), laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 165/168), laudo pericial (fls. 169/171), além do relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls. 187/189).

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pela decisão de fls. 68/78.

Notificado, o réu apresentou Defesa Prévia às fls. 209/210, através de Defensor Dativo.

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2021 e, não se verificando nenhuma hipótese de rejeição ou absolvição sumária, designou-se Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 213/216).

Realizada Audiência de Instrução e Julgamento, cindida em dois dias, as testemunhas arroladas foram ouvidas e, por fim, o réu foi interrogado (fls. 271/273 e 310/312).

Sobrevieram as alegações finais do Ministério Público, em resumo, pleiteando a condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado ou subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 ou, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e/ou prejudiciais a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência; em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito. Na situação sob julgamento, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 08/11, dos autos de exibição e apreensão de fls. 12 e 160, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 12, do laudo

definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 165/168 – no qual fora detectada a presença da substância tetrahydrocannabinol –, do laudo pericial de fls. 169/171, bem como através do Relatório de Mandado de Busca e Apreensão e das fotografias acostados aos autos do Processo 1500282-39.2021.8.26.0030 (fls. 15/24 e 66/73), e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra, além de qualquer dúvida razoável, que o acusado KLEYTON YUKYO ESUMI foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na peça acusatória, conforme será devidamente demonstrado a seguir.

Com efeito, a despeito das alegações da defesa Técnica e do réu em seu interrogatório, os elementos informativos reunidos na fase de investigação preliminar e as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um decreto condenatório.

Ouvida em sede policial, a testemunha Daniel Alves da Silva, policial civil, afirmou que: “é INVESTIGADOR DE POLÍCIA NESTA CIDADE E DURANTE INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE VEM OCORRENDO NESTE MUNICÍPIO, ONDE HAVIAM DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DA PARTICIPAÇÃO DO INDICIADO E OUTROS INDIVÍDUOS, INCLUSIVE ATRIBUINDO AO INDICIADO O COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FOI APREENHIDO EM FLAGRANTE O MENOR EMANUEL CONCEPCION AVELAR RIBEIRO, (RDO 422/2021), ONDE O MESMO CONFIRMOU QUE VENDIA DROGAS PARA O INDICIADO "JOTA", (JAPONES). DURANTE AS INVESTIGAÇÕES O SETOR DE INVESTIGAÇÕES LOGROU ÊXITO EM IDENTIFICAR O INDICADO E OS DEMAIS PARTICIPANTES O QUE CULMINOU PELA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA CONCESSÃO DE MANDADO DE BUSCAS EM DIVERSAS RESIDÊNCIAS NESTA CIDADE. NESTA DATA DE POSSE DESSES MANDADOS, POLICIAIS CIVIS DESTA DELGACIA DE POLÍCIA COM APOIO DE POLICIAIS DA REGIÃO E GUARDAS MUNICIPAIS DESENCADENARAM A OPERAÇÃO QUE CULMINOU NA DIIGENCIA REALIZADA. O DEPOENTE JUNTO COM O INVESTIGADOR ALEX E O GUARDA MUNICIPAL SARTI, DE POSSE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SE DIRIGIU A RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO JOÃO VITOR, ONDE O INDICIADO, ONDE O MESMO FOI LOCALIZADO. DURANTE AS BUSCAS, FOI LOCALIZADO NO QUARTO DO INDICIADO NUMA PRATELEIRA, UMA PORÇÃO A GRANEL DE MACONHA E NO SEU BOLSO DENTRO DE UMA CARTEIRA DE CIGARRO VAZIA, R\$ 663,00 REAIS EM DINHEIRO TROCADO, JÁ NUM BALCÃO NA COZINHA, DENTRO DE UMA GAVETA FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL E UM PACOTE CONTENDO SACOS DE SACOLÉ, COMUMENTE UTILIZADOS PARA EMBALAR DROGAS. DIANTE DISSO, O DEPOENTE DEU VOZ DE PRISÃO AO INDICIADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, APREENDEU OS OBJETOS E APRESENTOU NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS, QUE TEM CERTEZA DA PARTICIPAÇÃO DO INDICIADO NO TRÁFICO DE DROGAS NESTA CIDADE, INCLUSIVE QUE ELE É O 'PATRÃO' DA QUADRILHA E QUE O MEMSO NÃO TEM RESIDÊNCIA FIXA, SE UTILIZANDO DA CASA DE OUTROS ELEMENTOS PARA SE ECONDEN” (fl. 02). “EM ADITAMENTO AS SEU DEPOIMENTO ANTERIOR, ESCLARECE NA DATA DOS FATOS, DURANTE OPERAÇÃO PARA CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, ESTEVE NA RESIDÊNCIA DE JOÃO VÍCTOR E KLEYTON, UMA VEZ QUE OS MESMOS ESTAVAM RESIDINDO NO MEMSO LOCAL. FOI REALIZADO BUSCAS E LOCALIZADO MACONHA NO QUARTO DE KLEYTON . JOÃO VÍCTOR ESTAVA NA CASA E FOI APREENHIDO COM ELE APENAS PONTEIRAS DE CIGARROS DE MACONHA E UM DISCHAVADOR E 27 RAIS EM DINHEIRO (BO AG8673-1/2021), JÁ COM KLEYTON FOI LOCALIZADO MACONHA A GRANEL E R\$ 663,00 EM DINHEIRO. EM RELAÇÃO AS EMBALAGENS DE SACOLÉ E A BALANÇA DIGITAL, EMBORA TENHAM SIDO APREENHIDAS NA COZINHA DA CASA, ACREDITA QUE PERTENCE AO INDICIADO, POIS SEGUNDO O INFORMADO POR JOÃO VÍCTOR , ELE GUARDAVA SEPARADO DA DROGAS PARA ALEGAR QUE NÃO LHE PERTENCIA E ASSIM SE LIVRAR DE EVENTUAL ACUSAÇÃO DE TRÁFICO. EM RELAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE JOÃO VÍCTOR, EMBORA ELE NEGUE. AS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES QUE RESULTARAM NA REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO NAS RESIDÊNCIAS DOS INVESTIGADOS, APONTAM PARA A PARTICIPAÇÃO DELE ASSOCIADO A OUTROS INDIVÍDUOS NO TRÁFICO DE DROGAS NESTA CIDADE, FATO QUE É APURADO EM SEPRADO. ESCLARECE AINDA QUE DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA NÃO FORAM LOCALIZADO TELEFONES CELULARES EM PODER DE KLEYTON, MAS FOI LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA UM TELEFONE CELULAR SANSUNG, GALXYS A 32, PROVAVELMENTE DE PRORPIEDADE DE LARISSA FERNANDA BARBOSA ROSA E, COMO HAVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VERIFICAR OS APARELHOS DE CELULAR ALI ENCONTRADOS, FOI FEITO UMA BUSCA RÁPIDA E LOCALIZADO

CONVERSA DO INDICIADO RELACIONADOS A CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CUJO RELATÓRIO MINUCIOSO SERÁ OFERTADO POTERIORMENTE, RAZÃO PELA QUAL FORMALIZAMOS SUA APREENSÃO" (fl. 158).

Em seu depoimento em juízo, confirmou, sob compromisso legal, o quanto narrado anteriormente. Afirmou que o acusado já é conhecido dos meios policiais, por tráfico, e que, inclusive, já foi surpreendido fumando maconha nas proximidades da Delegacia; que recebera denúncia de moradores que o acusado estaria comandando a venda de drogas de adolescentes no bairro Pinheiros de Apiaí-SP; que, através de investigações, conseguiram apreender um dos adolescentes, de nome "Emanuel", e o ponto do tráfico era chamado de "Loja"; que foi mencionado pelo adolescente que o "patrão" era justamente o acusado; que, na data do fato deste processo, foi averiguada a casa do acusado, a partir de mandado de busca e apreensão que conseguiram, em decorrência das investigações relativas às suspeitas de que o acusado estava traficando na cidade, junto com outra pessoa chamada João Victor, que acabara de sair da cadeia do estado do Paraná por tráfico de drogas; que, na casa do acusado foram apreendidos uma porção de maconha, seiscentos reais em espécie, fruto das vendas das drogas, uma balança de precisão e alguns saquinhos comumente utilizados para embalar drogas; que, então, o acusado foi preso em flagrante; que já havia o conhecimento do envolvimento do acusado no crime, antes mesmo do testemunho do adolescente, uma vez que, o acusado já teria até cumprido pena por isso; que o acusado comandava "um tribunal do crime", para "julgar" aqueles que ele chefiava, quando estes não cumpriam o que ele esperava da venda; que a associação do acusado ainda esta sendo apurada em apartado, em outro procedimento policial; que há suspeita de vínculo com o PCC, ante a ostentação de armas dos adolescentes envolvidos, nas redes sociais, sendo certo que até mesmo acusado, quando ouvido em solo policial, confirmou que realmente fazia parte da facção.

Por sua vez, a testemunha e também policial civil Alex Miranda Amaral, confirmou, tanto em sede policial (fl. 159) quanto em juízo, o quanto narrado pelo seu colega de farda.

Também ouvida em solo policial, a testemunha João Paulo Sarti, guarda municipal, afirmou que: "O DEPOENTE É GUARDA MUNICIPAL NESTA CIDADE. QUE NESTA DATA FOI EM APOIO A POLICIAIS CIVIS DESTA DELEGACIA DE POLÍCIA EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO JOÃO VITOR, ONDE FOI LOCALIZADO O INDICIADO. QUE DURANTE AS BUSCAS FOI LOCALIZADO MACONHA E DINHEIRO NO QUARTO DO INDICIADO E UMA BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS TIPO SACOLÉ NUM BALCÃO NA COZINHA, SENDO O INDICIADO CONDUZIDO A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS" (fl. 04).

Por sua vez, em juízo, disse, sob compromisso legal, que, através do pedido da Polícia Civil, acompanharam a busca na casa do acusado, no bairro Santa Bárbara, mas não fizeram nenhuma diligência, somente acompanharam os policiais civis, prestando segurança e apoio aos mesmos; que, quanto aos fatos apurados neste processo, somente frisa não se recordar do nome do segundo indivíduo que estava no local no dia dos fatos.

Por seu turno, também ouvido pela Autoridade Policial, João Victor da Mota Telis de Oliveira narrou que: "MUDOU-SE DA CASA DE SUA MÃE, HÁ CERCA DE UM MÊS PARA O ENDEREÇO ACIMA INFORMADO, SENDO CERTO QUE O INDICIADO KLEITON, HÁ CERCA DE 15 DIAS FOI MORAR COM O DEPOENTE. QUE SABIA DA PATICIPAÇÃO DE KLEITON NO T´RAFICO DE DROGAS NA CIDADE, MAS AFIRMA QUE NÃO TINHA PARTICIPAÇÃO, É APENAS USUÁRIO DE MACONHA . QUE A BALANÇA E OS SAQUINHOS ACHADOS NA COZINHA DA CASA, PERTIENCIAM A KLEITON, ELE GUARDAVA SEPARADO DAS DROGAS, PARA TENTAR SE LIVRAR DE QUALQUER ACUSAÇÃO DE TRÁFICO, POIS ASSIM, CASO FOSS PEGO, PASSARIA APENAS POR USUÁRIO E ALEGARIA QUE OS OBJETOS PERTENCIAM A OUTRA PESSOA,. QUE SABE TAMBÉM QUE O LUCAS EMANUEL E O GORDUNHO VENDIAM DROGA PARA KLEITON, MAS DEIXA, CLAROVQUE NUNCA VENDEU

DROGAS PAR ELE, EMBORA ADMITA QUE SABIA DA CORRERIA QUE O KLEITON FAZIA. QUE EM RELAÇÃO A LARISSA, ACREDITA QUE ELA TAMBÉM NÃO TENHA NENHUMA PARTICIPAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS, ELA TINHA IDO ATÉ SUA CASA PARA FICAR COM O DEPOENTE, POIS É SUA EX NAMORADA E O CELULAR APREENDIDO NA CASA É DELA” (fl. 157).

Em juízo, ouvido na condição de informante em razão da amizade íntima mantida com o acusado, contou que é amigo do acusado e moravam na mesma casa; que tinha conhecimento que o mesmo fazia venda de drogas, uma vez que conversavam bastante, e que o acusado disse que vendia maconha, porém, não tinha conhecimento de que ele a armazenava dentro da residência; que não chegou a comprar drogas com o acusado; que o acusado guardava a balança e os saquinhos fora do quarto, na cozinha, para que, em uma eventual busca, não fosse acusado de traficante, mas sim de usuário; que sabia que “Lucas” e “Gordinho” vendiam drogas para o acusado, mas nunca fez parte disso; que Larissa não fazia parte também; que esta somente estava no local quando a Polícia chegou, uma vez que era sua namorada na época.

Por sua vez, a testemunha Larissa Fernanda Barbosa Rosa narrou, em sede policial, que: “NÃO TEM NENHUMA LIGAÇÃO COM O INDICIADO, FOI NAMORADA DO JOÃO VITOR, HOJE SÃO APENAS AMIGOS, EM RELAÇÃO AO KLEYTON, VULGO JAPONES, APENAS ERAM CONHECIDOS E NÃO SABE DIZER SE JOÃO VITOR TEM ALGUMA LIGAÇÃO COM ELE. O CELULAR APREENDIDO NA CASA DE JOÃO VITOR É SEU. ALEGA QUE TINHA CONHECIMENTO DE QUE KLEYTON PRATICAVA TRÁFICO DE DROGAS NESTA CIDADE, PORQUE JÁ FORA USUÁRIA DE DROGAS E JÁ COMPROU DROGAS DELE ANTERIORMENTE, ENTÃO ELE PEGOU INTIMIDADE E FICAVA LHE MANDANDO MENSAGENS PARA SE VANGLORiar E QUASE SEMPRE NAS OCASIÕES DESSAS MENSAGENS A DEPOENTE ESTAVA FORA DA CIDADE E NEM RESPONDIA ELE SOBRE O ASSUNTO. QUE DEIXA BEM CLARO NÃO TEM NENHUMA LIGAÇÃO COM O INDICIADO E JAMAIS VENDEU DROGAS OU TRABALHOU PARA ELE” (fl. 173).

Em juízo, sob compromisso legal, relatou que conhecia o acusado; que era namorada de João e sempre estava na casa deles; que, no entanto, não sabia que o acusado fazia venda de drogas no local, mas já tinha ouvido boatos; que, no momento do flagrante “estava no lugar, errado na hora errada”; que o celular que foi apreendido no local era seu; que já foi usuária de drogas e já comprou três vezes cocaína, porém foi antes do dia dos fatos; que as compras eram realizadas na rua, nunca na casa onde aconteceu o flagrante; que o acusado trocava mensagens com ela e, nessas mensagens, falava que era traficante, uma vez que, com isso, pensava em conquistá-la.

Por fim, interrogado em juízo, o réu KLEYTON YUKYO ESUMI confirmou apenas a posse da droga descrita na peça exordial, afirmando que havia adquirido para seu uso. Disse que a balança e os saquinhos que foram encontrados na casa que dividia com João não eram seus; que a porção que foi achada em sua casa era o que costumeiramente tinha em sua residência, uma vez que toda semana comprava cerca de vinte e cinco gramas, para seu uso próprio, pois é usuário desde os seus quatorze anos; que, na data dos fatos, estava em Apiaí apenas para resolver questões referentes à herança que sua mãe havia deixado, e não estava com nenhum envolvimento com tráfico na cidade; que a droga encontrada em seu quarto era para uso próprio e não para comércio; que o local onde comprava localiza-se no bairro Pinheiros, na linha do trem; que as informações vindas das testemunhas são falsas; que João deve ter algum rancor da sua pessoa, uma vez que já havia “ficado” várias vezes com a Larissa, o que explicaria os falsos testemunhos.

Primeiramente, no que tange ao depoimento de policiais, civis e militares, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas atuações, agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, nos quais o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O c. Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

No caso em apreço, os policiais civis que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu narraram, tanto em solo policial quanto em juízo, de forma harmônica e coerente, o envolvimento do acusado com a traficância, como pode ser observado dos depoimentos anteriormente transcritos.

Anote-se que, apesar de a quantidade de entorpecente apreendida não ser de expressiva monta, as circunstâncias do encontro das substâncias, isto é, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão judicialmente expedido no âmbito de investigação de crimes de tráfico e de associação para o tráfico na cidade (Processo nº 1500282-39.2021.8.26.0030), assim como a existência de mais de seiscentos reais em espécie em posse do acusado, em notas variadas, bem como de balança de precisão digital e embalagens plásticas (tipo “sacolê”) comumente utilizadas para preparo, embalo e posterior venda de entorpecentes (fl. 12), e após diversas “denúncias anônimas” de populares no sentido de que o acusado vinha traficando drogas na cidade, ocupando, inclusive, posição de comando na empreitada criminosa, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não (apenas) a finalidade para o uso próprio.

Ressalta-se, ademais, que, conforme documentos acostados às fls. 15/29 do Processo nº 1500282-39.2021.8.26.0030, verifica-se que o acusado postou diversas fotos em redes sociais ao lado de elevadas quantias de dinheiro em espécie, bem como de armas de fogo, circunstâncias que corroboram com a conclusão anterior.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza o delito. Nesse sentido, conforme trecho do v. Acórdão proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, “[p]or outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu KLEYTON YUKYO ESUMI, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na

denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Conforme a Teoria da Indiciabilidade ou da Ratio Cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude. Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento que aponte que ele agiu de forma justificada. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da Teoria Normativa Pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexiste nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu KLEYTON YUKYO ESUMI pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, verifica-se a impossibilidade da incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no caso em apreço, sendo certo que o benefício legal tem como finalidade prestigiar apenas os chamados “pequenos traficantes”, devendo, portanto, seus requisitos legais serem interpretados de forma restritiva.

Quanto ao acusado KLEYTON, a incidência da causa benéfica legal não se revela concretamente possível diante da comprovação de que vem se dedicando a atividades criminosas, já que, além de ser reincidente específico e portador de maus antecedentes (fls. 261/267 e 268/270), foi encontrado na posse de relevante quantidade de dinheiro em espécie em notas variadas e apetrechos para o tráfico, para além dos entorpecentes, bem como postou em redes sociais fotografias em que aparece na posse de armas de fogo e de expressivos montantes de dinheiro em espécie, circunstâncias que revelam que o acusado vinha fazendo da traficância seu meio de vida.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art. 5º, inciso XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado com antecedentes criminais, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor nos autos dos Processos nº 0000939-94.2017.8.26.0030 e nº 1500528-11.2020.8.26.0599 (fls. 261/267 e 268/270), sendo certo, no entanto, que apenas a segunda será valorada nesta fase da dosimetria da pena e, a primeira, na fase subsequente, considerando o que determina o Enunciado de Súmula nº 241 do c. Superior Tribunal de Justiça; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d)

Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e quantidade da droga: não devem ser valoradas negativamente, pois não extrapolam o ordinário à espécie. Assim, diante da presença de 01 (um) vetor desfavorecido, elevo a pena mínima cominada em 1/8 (um oitavo) e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I), considerando a condenação definitiva do réu nos autos nº 0000939-94.2017.8.26.0030 – trânsito em julgado em 06/11/2018, conforme informação de fl. 268. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas, devendo ser ressaltados os termos do Enunciado de Súmula nº 630 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Nesse sentido, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

Considerando que o tempo de prisão preventiva não alteraria o regime prisional, deixo de realizar a detração (CPP, art. 387).

Impede salientar, por fim, que o c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei nº 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo serem observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Por outro lado, nada impede a fixação de regime inicial fechado, diante da gravidade em concreto da conduta criminosa. A propósito:

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Dosimetria que não comporta reparo. Regime inicial fechado adequadamente imposto, diante da gravidade em concreto da conduta, aliada à reincidência. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Dias-multa. Inconstitucionalidade. Não reconhecimento. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJSP; Apelação 0016111-79.2018.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro: 04/02/2019)

Na situação ora em apreço impõe-se a adoção do regime inicial fechado, notadamente diante da reincidência específica e dos maus antecedentes do réu. Desta feita, nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, levando em consideração a pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Diante da quantidade de pena aplicada, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da execução da pena (CP, art. 77).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para condenar o réu KLEYTON YUKYO ESUMI, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

IV.I. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

V.II. Conforme determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores (fls. 68/78, 133/137, 243/245 e 287/288) e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do delito perpetrado pelo réu, da possibilidade concreta de voltar a delinquir, considerando a reincidência e os maus antecedentes, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que, em liberdade, não se afastará do distrito da culpa, sendo certo que há nos autos notícia de que não possui endereço fixo e vem mudando constantemente de residência para se furtar da Justiça.

V.II.I. EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

V.II.II. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020.

V.III. Considerando a demonstração de que o numerário apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal c/c art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos às fl. 12. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

V.IV. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

V.V. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado, intime-se o Réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado,

EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos conclusos para declaração da extinção da pena.

V.VI. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (Lei nº 11.343/06, art. 72), caso a providência já não tenha sido adotada.

V.VII. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

V.VIII. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Apiai, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA